

中华全国律师协会

律师办理电子数据业务 操作指引

(人大版)

(本指引由中国人民大学法学院证据学研究所起草, 仅限于
学术交流使用)

二〇一二年九月

目 录

第一章 总则.....	2
第二章 电子数据的取证.....	3
第一节 临场保护与外围调查.....	5
第二节 电子介质/数据的收集与固定.....	5
第三节 电子数据的检验分析.....	7
第三章 电子数据的审查判断.....	8
第四章 电子数据的举证与质证.....	9
第五章 有关电子数据的法律咨询.....	11
第六章 附则.....	11
附件 1 电子数据取证的一般流程	12
附件 2 电子设备提取工作记录	13

第一章 总则

第一条 为指导全国律师有效处理与电子数据相关的法律业务，提高律师业务水平与办案质量，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国行政诉讼法》及《中华人民共和国律师法》等相关法律法规的规定，结合电子数据的特点，制定本指引。

第二条 本指引所称的电子数据，是指用于证明案件事实的，以电子信息形式存在的数据。

电子数据主要存在于计算机、移动存储设备、移动通信设备、互联网等电子设备或介质中。电子数据可以依据不同标准区分为单机数据与网络数据，静态数据与动态数据，数据电文、附属信息、关联痕迹以及系统环境等。

电子数据既可以作为法定证据使用，也可以用作线索以获取其他证据。

第三条 本指引所称的电子设备，是指由电子元器件有机组合而成的，用于生成、传播、处理、存储电子数据的设备。

第四条 本指引所称的电子介质，是指存储、记录电子数据的介质。

第五条 律师办理的电子数据业务主要包括电子数据的取证、审查判断、举证、质证及相关法律咨询等。

为顺利办理上述电子数据业务，律师应当经过必要的专业培训。

第六条 律师办理电子数据业务应当遵守以下基本原则：

- （一）遵守国家法律法规的有关规定和普遍性的技术规范；
- （二）对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的电子数据依法承担保密义务。
- （三）重视电子数据与传统证据的结合使用；
- （四）保证电子介质和电子数据的完整性；
- （五）必要时邀请具有专门知识的人进行协助。

第二章 电子数据的取证

第七条 律师在办理案件过程中，应当根据不同的案情采取如下方式开展电子数据取证工作：

- （1）指导当事人开展电子数据取证工作；
- （2）自行开展电子数据取证工作；
- （3）聘请鉴定机构开展电子数据鉴定工作；
- （4）申请公证机关进行电子数据保全；
- （5）申请人民法院、人民检察院、仲裁委员会进行电子数据收集和保全；
- （6）请求网络服务商等第三人进行电子数据固定与保管。

律师采取第（1）、（2）、（3）种方式开展电子数据取证的，必要时可以申请公证机关进行全程录像公证、全程文字记录公证或提存镜像报告公证等。

律师采取第（3）、（4）种方式开展电子数据取证的，应当协助鉴

定机构、公证机关进行电子数据的范围审查。

第八条 律师办理刑事案件涉及电子数据的，应当向公安司法机关报案或报告，并根据本指引配合开展电子数据取证工作。

第九条 律师办理行政执法案件涉及电子数据的，应当向行政执法机关报案或报告，并根据本指引配合开展电子数据取证工作。

第十条 电子数据司法鉴定主要包括电子数据内容一致性的认定、对各类存储介质或设备存储数据内容的认定、对各类存储介质或设备已删除数据内容的认定、加密文件数据内容的认定、计算机程序功能或系统状况的认定、电子数据的真伪及形成过程的认定等。

律师根据诉讼需要委托进行电子数据司法鉴定的，可以同鉴定机构商定鉴定项目。

第十一条 电子数据公证主要包括电子数据的内容公证（网页公证、电子邮件公证、聊天记录公证、手机数据公证等）、电子数据的位置公证、电子数据的文本公证、电子数据的行为公证、镜像复制的行为公证、电子数据及取证报告的提存公证等。

律师根据诉讼需要申请进行电子数据公证的，可以同公证机构商定公证科目。

第十二条 律师开展或者协助、配合开展电子数据的取证工作，主要流程包括临场保护、外围调查、电子介质/数据的收集与固定、电子数据的检验分析等。

第十三条 律师开展或者协助、配合开展电子数据的取证工作，原则上应当对取证过程进行完整记录。

第一节 临场保护与外围调查

第十四条 律师发现电子设备中可能存在涉案电子数据的，应当及时采取或者协助、配合采取相关措施，对电子设备所在的场所、所接入的网络环境进行控制与保护。

第十五条 进行临场控制与保护时，律师应当避免或防止任何人采取可能导致原始电子数据发生改变的任何操作。

第十六条 进行临场控制与保护时，律师应当及时开展或者协助、配合开展外围调查，对有关的当事人陈述、证人证言、书证等进行收集、固定；必要时，律师应当及时对电子设备的购买记录、领用记录、归还记录以及使用情况等进行收集、固定，并制作相关笔录，请有关人员签章确认。

第十七条 律师发现电子设备正在运行、且继续运行可能会导致涉案电子数据灭失或受损的，应当根据具体情况采取或者协助、配合采取切断电源关机、断开网络等相应的应急措施。

第十八条 律师发现电子设备正在显示或生成涉案电子数据的，应当及时采取或者协助、配合采取拍照、录像等方式，对屏幕显示的内容进行记录。

第二节 电子介质/数据的收集与固定

第十九条 律师开展或者协助、配合开展电子数据的取证工作，必要时应当先提取电子设备上的指纹信息，采集汗液、毛发等生物样

本。

第二十条 律师开展或者协助、配合开展电子数据的取证工作，原则上应当制作原始电子介质的镜像复制件，并对原始电子介质进行封存，以避免或防止原始电子数据发生任何改变。

因客观原因不能封存原始电子介质或制作镜像复制件的，可以采取写保护方法对电子数据进行收集与固定，并妥善保管原始电子介质。

第二十一条 律师制作或者协助、配合制作原始电子介质的镜像复制件，应当确保原始电子介质的安全及其中数据的完整性。

因客观原因不能封存原始电子介质或者不能保证电子数据的完整性的，应当向当事人说明事由及可能产生的影响，并征得当事人的书面同意。

第二十二条 律师封存或者协助、配合封存原始电子介质的，应当记录反映其特定性的外观信息（包括序列号、识别码、用户标识、品牌、厂商、型号、容量等），并注明或告知妥善保管的注意事项。

第二十三条 律师制作或者协助、配合制作镜像复制件，应当交由或聘请具有相关资质或能力的专业人员实施，并记录反映其中电子数据完整性的校验信息。

必要时，律师可以将含有校验信息的镜像复制报告提交公证处，进行提存公证。

因客观原因无法产生校验信息的，律师应当采取封存介质等保护电子数据完整性的适当措施。

第二十四条 律师申请公证机关对网上电子数据进行公证保全的，应当要求采取录屏软件或录像进行记录。保全的内容除了涉案网页外，可以一并对有关的网页快照或转载进行公证保全。

第二十五条 对于利害关系人没有争议的或档案部门正常保管的电子数据，律师可以采用打印、拍照等方式转化为纸质文档，并请当事人或证据持有人在纸质文档上签章确认，必要时邀请见证人进行见证。

第二十六条 电子介质及数据的运输、保管应当做好防磁、防震、防热、防潮等措施，以免导致介质损坏或数据变化。

保管、转移或使用电子介质应当同步制作相应的保管记录、转移记录和使用记录。

第三节 电子数据的检验分析

第二十七条 为查明案件事实的需要，律师可以对电子介质中的电子数据进行检验分析。需要采取技术手段的，律师可以邀请具有专门知识的人协助，或者配合具有专门知识的人开展工作，共同制定电子数据检验分析方案。

第二十八条 律师开展电子数据检验分析工作，原则上通过制作复制件或者写保护方式进行。

第二十九条 律师开展电子数据检验分析工作，可以按照涉案人员、时间顺序、争议事实等要素进行，必要时可以聘请具有专门知识的人采取关键词过滤、可疑文件审查、数据挖掘等方法进行技术辅

助。

第三十条 律师开展电子数据检验分析工作，应当全面调取数据电文、附属信息、关联痕迹以及系统环境证据，并进行综合评断。

第三十一条 律师开展电子数据检验分析工作时发现涉案电子数据的，应当以此为线索扩大查找其他涉案的电子数据和传统证据，以重建虚拟空间的案件事实。

第三十二条 对于电子介质中涉案电子数据是否真实等专业性问题存在疑问的，律师可以自行委托或者申请有权机关委托司法鉴定或者文证审查，也可以收集固定有关的传统证据、来自第三方的电子数据等进行佐证。

第三章 电子数据的审查判断

第三十三条 律师应当对电子数据的可采性与证明力进行审查判断，重点审查电子数据的合法性、关联性、原始性、真实性、完整性与充分性。

第三十四条 律师对于本方收集但存在手续欠缺、程序瑕疵等问题的电子数据，应当采取适当方法予以补强或转化。

第三十五条 律师审查电子数据的关联性，应当结合待证事实进行文本审查，必要时可以通过技术手段进行辅助。

第三十六条 律师审查电子数据的完整性与真实性，应当考察如下方面：

（1）收集的电子数据由哪一方当事人或第三人保管及保管的方

法；

- (2) 电子数据是否由电子设备正常运行而产生；
- (3) 电子数据的内容是否得到完整提取和精确复制；
- (4) 收集的有关外围信息是否全面；
- (5) 收集的笔录、保管记录等是否构成完整的证据保管链；
- (6) 采取的保管措施能否确保取证原始介质及其中的电子数据至提交时没有发生实质性的变化。

必要时，律师可以聘请具有专门知识的人对电子数据的内容及取证措施进行技术性审查，判断是否存在技术问题。

第三十七条 律师审查评断电子数据的证明力，应当考察电子数据之间、电子数据与传统证据之间是否构成完整的证据体系。

第三十八条 律师对电子数据进行审查判断后发现在网络服务商、网站等第三方另存有电子数据的，可以自行调查或者申请人民法院、人民检察院、仲裁委员会调取。

第三十九条 律师对电子数据进行审查判断后发现对方当事人藏匿电子数据的，可以申请人民法院、人民检察院、仲裁委员会责令对方当事人进行提交。

第四章 电子数据的举证与质证

第四十条 律师向法庭提交电子数据，应当一并提交电子数据所在的原始电子介质。因客观原因不能提交原始电子介质的，应当说明理由。

第四十一条 律师向法庭提交电子数据，可以通过书面打印件、取证报告、鉴定意见书或公证文书等方式；必要时，还可以以列表的方式对电子数据进行归纳整理，并以书面报告的方式进行说明。

第四十二条 律师向法庭提交电子数据需要展示的，可以根据电子数据的具体类型，借助多媒体设备出示、播放或演示。必要时，律师可以聘请有专门知识的人进行操作，并就相关技术问题直接作出说明和解释。

第四十三条 律师对于非法取得的电子数据，应当申请法庭予以排除。

第四十四条 律师对电子数据进行质证时，应当重点围绕电子数据的真实性、完整性、原始性以及证明力等内容。

第四十五条 对于电子数据的专业性争议问题，律师可以申请采用以下方法解决：

- （1）庭上模拟演示；
- （2）申请专家证人进行解释与说明；
- （3）申请司法鉴定；
- （4）其他合理的方法。

第四十六条 对于电子数据鉴定意见书有异议的，律师应当申请法庭传唤司法鉴定人到庭接受询问。

对于电子数据公证书有异议的，律师可以申请法庭传唤公证人员到庭接受询问。

必要时，律师可以聘请具有专门知识的人帮助询问。

第五章 有关电子数据的法律咨询

第四十七条 律师依法开展的电子数据法律咨询业务包括：

- （1）关于电子数据的法律规范；
- （2）关于电子数据的技术规则；
- （3）中外关于电子数据的制度差异；
- （4）电子数据的取证、举证、质证与认证方法；
- （5）具体案件中电子数据的适用；
- （6）其他关于电子数据的法律问题。

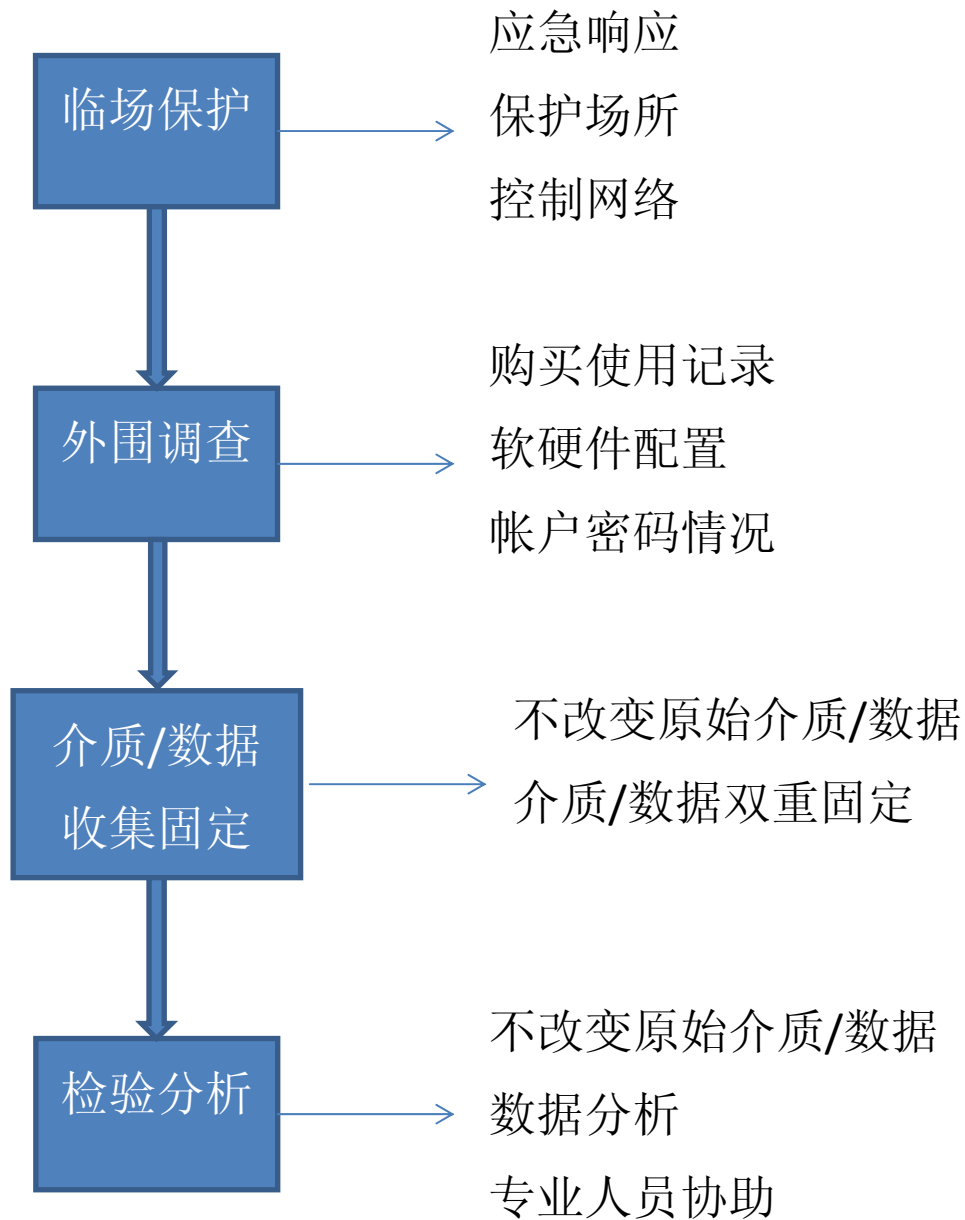
第六章 附则

第四十八条 本指引由中华全国律师协会制订并负责解释。

第四十九条 本指引仅为指导建议或行为参考类文件。若律师在办理电子数据业务中未采取或未参考本指引的，并不必然构成该律师执业行为不当。

第五十条 本指引于公布之日起施行。

附件 1 电子数据取证的一般流程



附件 2 电子设备提取工作记录

项目	内容	有无	具体情况（可附件）	签章 日期
来源	购买记录			
	发放领用 记录			
	收回归还 记录			
使用情况	使用者			
	使用者计 算机水平			
	用途			
	使用期间			
配置 情况	硬件配置			
	软件配置			
	网络配置			

	其他外设			
帐 户 密 码	系统登陆 帐户			
	上网帐户			
	邮件帐户			
	即时通讯			
	网络存储			
	其他帐户			
当 前 运 行 情				
备 注				